

1501229-52.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237096/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 13778014 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2196/20/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501229-52.2020.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501229-52.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237096/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 13778014 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2196/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2237096 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2237096 - 01º D.P. TUPÃ, 2196/20/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LUIS PORTATE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

EDSON LUIS PORTATE, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos narrados na denúncia de fls. 114/115.

Diante da suspensão das audiências de custódia conforme Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 232/2020, a legalidade da prisão em flagrante foi analisada judicialmente, tendo sido concedida liberdade provisória, com a fixação de medidas

cautelares, conforme decisão de fls. 76/80.

Após o oferecimento da denúncia (fls. 114/115), por decisão de fls. 119, foi determinada a notificação do acusado para oferecimento de sua defesa preliminar. Notificado (fls. 126), o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 137/139.

Recebida a denúncia a fls. 142/144, o feito restou saneado, tendo sido determinada a citação do réu e designada audiência de instrução.

Citado (fls. 188), o réu se tornou revel, ante ao não comparecimento na audiência de instrução (fls. 189/197).

Ainda em audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e declarado o encerramento da instrução, com a manifestação de ambas as partes em alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, estando comprovadas materialidade e autoria, nos termos da denúncia; enquanto a Defesa, pela absolvição em razão da ilicitude e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, em especial pela pouca quantidade de droga apreendida. Não sendo o caso, requer aplicação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Capítulo II - Da Motivação

Trata-se de ação penal pública condicionada onde colima o Ministério Público a condenação do acusado EDSON LUIS PORTATE, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

O conjunto probatório reunido nos autos foi suficiente para a comprovação tanto da materialidade como da autoria delitivas.

A materialidade restou devidamente comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, da nota de culpa de fls. 05, o boletim de ocorrência de fls. 06/08, dos autos de exibição e apreensão de fls. 09, das fotografias de fls. 10/11, do laudo de constatação de fls. 13/16, confirmado pelo laudo definitivo de entorpecentes de fls. 133/136 e do relatório final da investigação de fls. 108/110. Também se extrai a materialidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto no decorrer na investigação criminal, quanto em audiência. Aliás, sabendo tratar-se a materialidade da constatação da efetiva ocorrência do delito, pode ser ela caracterizada também através da prova testemunhal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (Neste sentido: TJSC; Ap. crim. n. 00.000473-1; Relator Des. Amaral e Silva).

A autoria do acusado também é certa.

As testemunhas ALAN GONÇALVES FERREIRA e JESIMIEL DOS SANTOS, policiais militares, ratificaram as declarações prestadas no inquérito policial. Disseram que no dia da abordagem estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima de que o indivíduo de alcunha "Maconha" estava realizando a mercancia de entorpecentes em frente a sua casa. Chegando na esquina de sua casa, avistaram-no em atitude suspeita, já que, disfarçadamente, entrou em sua residência, vindo a fechar todas as portas. Contudo, como a casa não era murada, foi possível visualizá-lo no interior da residência, indo ao banheiro com uma sacola. Ao ouvirem o disparo da descarga, foram até a caixa de esgoto e, com a movimentação da água, encontram um invólucro amarelo contendo 09 porções de substância parecida com "crack". Nesse momento, relatam ter chamado o réu que, vindo a confessar a posse da droga, também autorizou a busca domiciliar. Nesta, foram encontrados mais 26 porções semelhantes da droga embaixo do fogão, tendo sido decretada a prisão em flagrante. Indagados, os policiais confirmaram que o réu já era conhecido por tráfico, embora nenhum deles já tenha realizado outro flagrante semelhante. ALAN ainda esclareceu que, na ocasião, o réu tão somente confirmou a propriedade da droga, nada dizendo a respeito de sua destinação. Por sua vez, na oportunidade que teve de apresentar sua versão dos fatos, o réu restou revel. Em solo policial, porém, ele confessou a propriedade integral da droga, mas disse ser toda para seu próprio consumo, sendo dela usuário. Na ocasião, confirmou a versão apresentada pelos policiais militares,

tanto no tocante a localização das primeiras porções da droga em sua rede de esgoto, quanto a posterior abordagem policial e sua voluntariedade em permitir-lhes acesso ao interior de sua residência.
Pois bem.

Em que pese o esforço da defesa, não se mostra possível a declassificação do crime àquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, tampouco o reconhecimento da suposta legalidade da abordagem policial ou ilicitude da prova, sendo a procedência dos pedidos medida que se impõe.

Verifica-se que o depoimento das testemunhas policiais foram coerentes, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma fraudatória ou abusiva, não sendo suas condições funcionais elementos justificadores de impedimento ou suspeição. Isto é, o depoimento de policial "obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcionar" (RT 752/589). Tem-se proclamado, de forma reiterada, que a circunstância de a testemunha ser policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir o HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido trago a luz da Apelação nº 990.09.187986-0, julgada pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25 de fevereiro de 2010:

"Esta Câmara tem seguidamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados".

Aliás, sobre o ônus da prova, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão as conclusões alcançadas nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional. Para tanto, soa adequado rememorar, com espreque na lição de Aury Lopes Júnior, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, "entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações" (Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009, pag. 45). Em outras palavras, segundo o ensinamento do abalizado professor Aury Lopes:

"O que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa". (Grifo no original) (ob. cit.).

Sendo assim, houvesse prova concreta acerca dos abusos cometidos durante a abordagem, caberia à defesa reuni-la aos atos. Contudo, além do acusado ter confirmado sua voluntariedade ao acesso dos policiais em sua residência, a Defesa se limitou em tecer meras alegações, não de desincumbido do ônus insculpido no caput do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Também não haveria que se pronunciar pela suposta ilicitude da prova, uma vez que não decorre de qualquer atuação ilícita dos policiais militares por suposta violação de domicílio, sobretudo porque os policiais, tanto perante a autoridade policial, como em Juízo, frisaram que o acusado após admitir a propriedade da droga encontrava em sua caixa de esgoto, autorizou sua entrada na residência, onde veio a ser encontrado o restante da droga.

No mesmo sentido, conforme afirmado por ambas testemunhas, a abordagem foi motivada

não só a partir do recebimento de uma denúncia anônima de que o réu, que atende pela alcunha "Maconha" (fls. 48), estava traficando em frente a sua residência, mas também da sua atitude suspeita ao entrar na residência logo após perceber a aproximação policial.

Além disso, anteriormente a busca domiciliar, foi possível visualizar a tentativa de ocultação da droga pelo acusado pelo vidro da janela de sua residência, que culminou no flagrante da droga em sua rede de esgoto.

Por consequência, havendo forte indício do cometimento de crime de natureza permanente, ainda que sem a voluntariedade do réu, não haveria ilegalidade da ação policial, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da praticado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido" (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

No tocante a desclassificação do crime, cumpre observar que, mesmo a quantidade de droga sendo de pequena monta (3,98g), não se pode ignorar que se encontrava separada em 36 (trinta e seis) porções individualizadas que, somada a sua própria natureza, mostra-se incompatível com sua alegação de ser meramente para consumo próprio.

Contudo, considerando que o passado criminoso do réu dista de mais de 15 (quinze) anos do flagrante em análise, mostra-se possível afastar seus maus antecedentes. E assim, por ser trabalhador rural e primário, sem indícios de envolvimento com o crime organizado ou que se dedique com habitualidade ao crime, a baixa quantidade da droga apreendida permite que seja agraciado com a benesse insculpida no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada - Necessidade - Cabível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1501147-37.2020.8.26.0567; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022)

Neste contexto, incorreu, pois, o acusado VÍTOR HUGO SERRA, nas sanções do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Capítulo III – Da Dosimetria

Na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, e às do art. 42 da Lei n. 11.343/06, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal a espécie.

O réu não possui maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos suficientes para avaliação percutiente. As circunstâncias devem ser consideradas normais a espécie. Os motivos e as consequências do crime não foram apurados. Por estas razões, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, devendo permanecer a pena intermediária também no mínimo legal. Por derradeiro, na terceira fase, há de se considerar a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, que o faço em seu grau médio, já que, mesmo sendo de pouca quantidade, a natureza da droga apreendida é extremamente nociva, de forma que fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Não se olvide que a redução máxima do privilégio somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado.

No que concerne à pena pecuniária aplicada, o valor de cada dia multa será de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do CP, bem como artigo 43, da Lei nº 11.343/2006, em razão da falta de prova acerca a condição econômica do réu.

Tendo em vista a natureza do crime, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime aberto para o acusado iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Verifico, no entanto, que, na situação em tela, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que a ré preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, o que revela ser a substituição suficiente à repressão do delito. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, §2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, §1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta. A primeira consistirá em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no § 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado. A segunda consistirá no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo nacional vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento no Município de Valinhos, que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado e, a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá o condenado ser cientificado da possibilidade do cumprimento da pena restritiva de direito em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), que nunca deve ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

Da mesma forma, em audiência admonitória, caberá ao Juízo da Execução indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto

para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Capítulo IV - Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado EDSON LUIS PORTATE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no valor, cada uma, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº. 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP) consistentes na prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme disposto no § 3º do artigo 46 do Código Penal, e o pagamento de 1 salário-mínimo nacional, convertido em cestas básicas, a ser pago a entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da multa e da suspensão do direito de dirigir imposto em razão do crime do artigo 303, CTB.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Tome-se as providências para intimar-se o réu, por intermédio do Juízo de Execução, para audiência admonitória, com o fito de iniciar o cumprimento das penas restritivas de direitos que lhe foram irrogadas, nos termos do art. 149, §2º, da LEP; 4) Comunique-se a(os) ofendido(s) do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal; 5) Proceda-se à cobrança da pena de multa, na forma do art. 49 e seguintes do Código Penal.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas pelo réu, ficando-lhes concedido os benefícios da gratuidade processual. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, se o caso.

P.I.

De São Paulo para Tupã, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA